

1502226-17.2021.8.26.0664

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANO SANTOS DE LIMA

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... pela Polícia por envolvimento com o tráfico de drogas. Nos últimos dias antes da prisão surgiram várias denúncias e informações privilegiadas da prática do tráfico de drogas por ele. Investigações desvendaram o modus operandi de Gabriel. Ele comprava em torno de 10g, fracionava e vendia. Praticava o tráfico de drogas na própria casa. No dia dos fatos receberam ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Rua Espírito Santo Nº 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

1502226-17.2021.8.26.0664 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502226-17.2021.8.26.0664

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2130656/2021 - DISE-

DEL.SEC.VOTUPORANGA, 17895922 - DISE- DEL.SEC.VOTUPORANGA, 32/21/526 - DISE-

DEL.SEC.VOTUPORANGA, 2130656 - DISE- DEL.SEC.VOTUPORANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel Sebastian Souza da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANO SANTOS DE LIMA

Vistos.

GABRIEL SEBASTIAN SOUZA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia, hora e local descritos, o denunciado, em tese, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 07 porções de "crack", cinco delas já individualmente embaladas e prontas para a venda, e duas delas ainda sem fracionar, as quais seriam suficientes para preparar pelo menos 50 porções individuais para a venda, todas com peso líquido de 10,3g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 61/65).

O denunciado foi notificado e citado. Apresentou defesa (fls. 132/134).

A denúncia foi recebida (fls. 139/140).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas de acusação e as de defesa. Ao final, o acusado foi interrogado.

Em alegações finais a acusação requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, enquanto a defesa requereu a absolvição do acusado e deduziu subsidiárias.

É o relatório. Decido.

Não há preliminares ou prejudiciais ao mérito. Por outro lado, encontram-se presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Em virtude disso, avanço diretamente à análise do mérito.

O art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 prevê como crime as seguintes condutas, in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

O bem jurídico tutelado pela norma penal é a saúde pública, de forma que o delito é de perigo abstrato e se consuma com a prática efetiva de qualquer das condutas previstas no tipo incriminador. Droga, no caso, como elemento normativo do tipo, é toda substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, assim considerada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e listada na Portaria SVS/MS 344, de 12/05/98.

O elemento subjetivo do tipo é o dolo genérico, consubstanciado na vontade e consciência de praticar uma das várias condutas nucleares do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo o agente pleno conhecimento de que a droga é entorpecente ou que causa dependência física ou psíquica, e que o faz sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ainda, é crime de mera conduta, sendo irrelevante a prova da comercialização.

Passo a analisar os elementos de prova colhidos.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 20/23), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 24/25), pelo laudo de constatação preliminar (fls. 27/29), pelo exame químico-toxicológico definitivo, indicando que foi detectada a presença da substância cocaína no material analisado (fls. 105/107) e pela prova oral produzida.

A substância em questão encontra-se presente na relação de substância de uso proscrito no Brasil, conforme o disposto na Portaria 344/98 do SVS/MS e suas atualizações.

A autoria é incontestada.

A testemunha de acusação, Augusto Cesar da Silva, disse, em juízo, que chegaram muitas denúncias indicando a traficância praticada por Gabriel. Em investigações verificaram que as denúncias eram verídicas. Gabriel colocava uma cadeira em frente à própria casa e aguardava os usuários. Fizeram a investida policial e localizaram cinco porções prontas para a venda e mais duas porções de cinco gramas cada. Tudo indica que Gabriel adquiria pequena quantidade para vender no mesmo dia. Caso fosse pego, perderia pouca droga. Gabriel negou no início, mas após assumiu a traficância e indicou onde as drogas estavam escondidas. As diligências anteriores consistiam em passagens no local para constatar a veracidade da denúncia. No local é impossível fazer campana. Nas vezes que passaram pelo local os usuários não encostavam. Sempre viram Gabriel sentado na calçada.

A testemunha de acusação, Luis Fernando Quadreli, disse, em juízo, que Gabriel já era conhecido pela Polícia por envolvimento com o tráfico de drogas. Nos últimos dias antes da prisão surgiram várias denúncias e informações privilegiadas da prática do tráfico de drogas por ele. Investigações desvendaram o modus operandi de Gabriel. Ele comprava em torno de 10g, fracionava e vendia. Praticava o tráfico de drogas na própria casa. No dia dos fatos receberam informações privilegiadas de que

Gabriel estava vendendo drogas. Abordado, Gabriel admitiu a traficância e indicou onde havia enterrado as cinco pedras de "crack". Ele indicou ainda outras 10g a fracionar. Fez campanas, mas não tinha como ficar parado, pois o local é repleto de usuários e outros traficantes. Gabriel ficava sentado numa cadeira aguardando usuários. As drogas estavam no quintal da casa dele, ao lado de onde Gabriel ficava. Essas drogas estavam camufladas sob a terra. Gabriel disse que comprava em torno de 10g, por R\$ 250,00. Ele vendia por R\$ 10,00, cada pedra, e arrecadava o dobro do que pagava. Ele ainda estava no cumprimento de pena, em regime aberto. Gabriel, a princípio, negou a traficância. Após ser convencido que sua conduta era conhecida dos policiais, ele assumiu a traficância e colaborou com as investigações.

A testemunha de defesa, Neusa de Fátima Arena, disse que conhece Gabriel por meio dos filhos. Gabriel fazia bico como servente, pintor, o que aparecesse. Quando aparecia trabalho, Gabriel trabalhava. Já viu Gabriel trabalhando. Já contratou serviço de Gabriel. Era serviço braçal. Soube da prisão em razão de boatos no bairro.

Interrogado em juízo, o réu GABRIEL SEBASTIAN SOUZA DA SILVA confessou a prática delitiva. Disse que, antes de ser preso, fazia bicos no que aparecesse. Já teve envolvimento com a Justiça por tráfico de drogas. Foi condenado. Estava "assinando" em liberdade. A acusação é verdadeira. Acordou de manhã e já estava com a droga ("crack") na residência. Não pode dizer de quem comprou. Comprou em Votuporanga. Pagou R\$ 250,00. Parte dessa droga seria vendida e outra parte seria consumida pelo interrogando. Vendia o entorpecente na rua. Cada porção era vendida por R\$ 10,00. Os policiais chegaram e entraram na casa do interrogando. Eles disseram que sabiam que tinha droga no local. Indicou onde o entorpecente estava. Toda a droga estava enterrada próximo a uma árvore. O próprio interrogando foi quem enterrou o entorpecente. Não viu se a droga estava fracionada. Lucrava o dobro do valor pago pela droga. Vendia apenas "crack". Fracionava a substância com a própria mão e esse fracionamento era feito dentro da casa do interrogando.

A confissão do acusado, de que, efetivamente, a droga apreendida era sua e que praticava a venda de "crack" a usuários, apresenta destacado valor probante para fins de formação do convencimento judicial. Inicialmente, destaca-se a sua harmonia intrínseca, não apresentando qualquer contradição entre seus próprios termos, sendo absolutamente verossímil. Por outro lado, apresenta harmonia extrínseca, encontrando respaldo em outros elementos de prova coligidos na instrução processual, em especial quando comparada ao laudo de exame-químico toxicológico e à prova oral colhida em juízo.

A prova se mostrou suficiente para comprovar que a droga estava efetivamente em poder do réu e se destinava ao tráfico, não havendo que se falar em desclassificação para uso de entorpecente.

Nunca é demais lembrar que o testemunho policial goza de credibilidade tanto quanto outro qualquer, sendo que, para ter retirado o seu valor probante, é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de elementos de convicção. Aliás, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e, depois, negar-lhes crédito quando prestassem conta de suas diligências. Em outras palavras, o depoimento policial não merece reparo, sendo que a jurisprudência é uníssona ao reconhecer a validade das declarações prestadas por policiais.

Realmente, "(...) É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" (STF 1ª T. HC87.662/PE Rel. Min. Carlos Britto j. 05.09.2006 DJU 16.02.2007 LexSTF 339:417).

No mesmo sentido, "(...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante" (LexSTJ 125:338). Destarte, "(...) Nada existe nos autos que possa desabonar os depoimentos

dos policiais, invocados na sentença, confirmada no acórdão. Além da comprovação da materialidade do delito, a prova testemunhal decorrente de declarações dos policiais foi colhida, em juízo, assegurado o contraditório, inexistindo qualquer elemento a indicar pretendessem os policiais incriminar inocentes" (STF 2ª T. HC 77.565/SP Rel. Min. Néri da Silveira j. 29.09.1998DJU 02.02.2007, p. 74). Outrossim, a título de argumentação, como bem destaca o seguinte julgado, a denúncia anônima representa importante instrumento no combate ao tráfico de drogas:"(...) No tocante à delação anônima, não se pode olvidar que as notícias-crime levadas ao conhecimento do Estado sob o manto do anonimato têm auxiliado de forma significativa na repressão ao crime. Essa, inclusive, é a razão pela qual os órgãos de Segurança Pública mantêm um serviço para colher esses comunicados, conhecido popularmente como 'disque-denúncia'. Assim, não há ilegalidade na instauração de investigações deflagradas por denúncia anônima, eis que a autoridade tem o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados, desde que se proceda com a devida cautela, o que se revela no presente caso, pois tanto a investigação quanto a ação penal foram conduzidas dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação vigente. (...) Ademais, in casu, a delação anônima culminou com a elucidação dos fatos, não podendo ser taxada de mendaz ou infundada" (TJSP- 4ª Câmara de Direito Criminal- Ap0002118-10.2015.8.26.0620/Taquarituba - Rel. Des. Camilo Léllis - j. 09.08.2016).

Neste sentido, toda a prova judicial, corroborada pela não menos robusta prova extrajudicial. Vai daí, pois, a condenação do réu é do mais absoluto rigor, muito bem provada nos autos a sua autoria criminoso, mercê de provas idôneas e suficientes à sua responsabilização criminal. Tanto é que, em situações praticamente idênticas às dos autos, decidiu-se:

"MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - comprovação que o material apreendido é droga- maconha e cocaína. AUTORIA - depoimento policial que indica a apreensão de droga - validade - depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - destinação a terceiros - indícios tais como quantidade incompatível com a figura de usuário; falta de capacidade econômica para o réu possuir a droga apreendida para seu uso pessoal; apreensão de quantia em dinheiro; denúncia anônima confirmando a traficância - tipo congruente (...)" (TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Ap 0001689-65.2015.8.26.0160/Descalvado - Rel. Des. Lauro Mens de Mello - j. 24.05.2017); "Apelação - Tráfico de drogas (art. 33, 'caput', § 4º da Lei 11.343/06) - Recurso defensivo - Preliminar - Nulidade - Ilegalidade de provas - Busca e apreensão realizada em sua residência não foi precedida de ordem judicial - Inocorrência - Delito permanente - Prescindível o mandando de busca e apreensão na prisão em flagrante - Precedentes do STJ - Preliminar rejeitada. Mérito - Absolvição pretendida - Insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria demonstradas - Apreensão de 144 invólucros plásticos de cocaína, pesando 34,78g e a quantia de R\$ 80,00, em posse do acusado - Firmes e coerentes depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela diligência - Condenação de rigor - Desclassificação da conduta imputada ao agente para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - A quantidade, natureza e a forma de acondicionamento das drogas, aliadas às circunstâncias fáticas do delito, revelam a traficância. Dosimetria - A pena fixada não merece qualquer tipo de reparo - Regime fechado de rigor - Trata-se de crime hediondo, em que há a necessidade de maior repressão criminal. Recurso improvido." (TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Ap 0034755-05.2014.8.26.0602/Sorocaba - Rel. Des. Salles Abreu - j. 04.11.2015). Caracterizado, portanto, a traficância, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, presente o elemento subjetivo do tipo, restando evidenciada a conduta dolosa do acusado, agindo com a vontade e consciência necessárias. A conduta típica é antijurídica, não havendo qualquer causa justificante para a realização dela. De acordo com a teoria da ratio cognoscendi, segundo a qual a tipicidade da conduta induz a antijuridicidade, a prova acerca da existência de uma justificativa fica a cargo da defesa, ônus do qual o réu não se desincumbiu. Em termos de culpabilidade,

o acusado é imputável, já que maior de 18 anos de idade, além de não se enquadrar nas situações do artigo 26, caput e parágrafo, do Código Penal; tinha consciência da ilicitude de sua conduta; e lhe era exigível comportamento de acordo com o direito, não tendo sido suscitada hipótese de inexigibilidade de conduta diversa. Em observância ao artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República, bem como ao artigo 68 do Código Penal, passo a individualizar a pena segundo o método trifásico elaborado por Nélson Hungria.

Na fixação da pena, antes, sempre atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e respeitado o sistema trifásico, nada há a ser valorado em sede de primeira fase de dosimetria da pena, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Observo que o réu é reincidente específico (fls. 43). Entretanto, durante seu interrogatório prestado perante o Juízo, confessou o crime e revelou detalhes de sua execução, motivo pelo qual compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Observo, ainda, que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos, a atrair a incidência da atenuante da menoridade relativa. Mantenho, todavia, a pena intermediária no patamar outrora estabelecido, pois, à luz do entendimento previsto no Enunciado nº 231 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Não há que se falar em agravante da calamidade pública pois não se evidenciou que a prática do ilícito estivesse relacionada à pandemia de Covid-19.

Por fim, na terceira fase de dosimetria da pena, entendo não ser possível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que o réu é reincidente específico, a denotar, de modo objetivo, a dedicação a atividades criminosas, sobretudo ao tráfico de drogas, o que afasta a aplicação do redutor legal.

À míngua de causas legais ou especiais, a autorizar novas modificações, torno definitivas as penas até aqui encontradas, pois, suficiente para a punição e consentânea com a capacidade econômica do réu.

À vista do quantum de pena aplicado e da reincidência específica, o regime para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade será o FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Ressalte-se que, embora deva ser considerado para fins de detração, na forma do artigo 42 do Código Penal, o período de prisão preventiva não se mostra suficiente para influenciar na fixação do regime inicial.

Ante a ausência de dados concretos a respeito da situação econômica do réu, arbitro o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, em 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, a ser devidamente atualizado no momento da execução, pelos índices de correção monetária adotados por este Tribunal (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 49, §§1º e 2º, do Código Penal).

Conquanto o STF já tenha declarado inconstitucional a proibição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena privativa de liberdade aplicada supera 4 (quatro) anos e o condenado é reincidente em crime doloso, o que impede a sua substituição por medidas restritivas de direitos (artigo 44, I e II, do Código Penal).

Igualmente incabível a suspensão da execução da pena, porquanto superados os dois anos previstos no artigo 77, caput, do Código Penal.

Deixo de fixar indenização mínima à vítima (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal), pois o crime é vago, não havendo vítima definida.

Por todas as razões expostas, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o réu GABRIEL SEBASTIAN SOUZA DA SILVA, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, estes fixados em 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Tendo em vista o regime fixado para o início de cumprimento da pena, a reincidência e, ainda, a subsistência dos motivos que outrora fundamentaram o decreto preventivo, MANTENHO a prisão cautelar do réu, como forma de acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos delitos (artigo 312 do Código de Processo

Penal).

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Oportunamente, expeça-se guia de execução provisória.

Condene o(a)s sentenciado(a)s também ao pagamento das custas e despesas processuais.

Declaro o perdimento dos valores apreendidos em favor da União (fl. 24), na forma do art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, os quais deverão ser revertidos diretamente ao Funad.

Transitada em julgado da presente condenação:

A) destruam-se as amostras guardadas para contraprova, certificando nos autos, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006;

B) coloquem-se os valores perdidos (fl. 24) à disposição da União (Funad);

C) expeça-se guia definitiva de cumprimento da pena;

D) intime-se o réu para pagar a pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, a teor do artigo 50 do Código Penal;

E) comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição da República; e

F) lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Oportunamente, arquivem-se os autos, observando-se as formalidades legais.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Votuporanga, 12 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA